

<제01장 행정소송의 일반론.제03절 행정소송의 한계>

[기출][2022-1-2]관할행정청의 처분 전에 제3자가 예방적으로 처분 금지를 구하는 소송의 허용 여부

《[문제1] 채석업자 丙은 P산지(山地)에서 토석채취를 하기 위하여 관할행정청 군수 乙에게 토석채취허가신청을 하였다. 乙은 丙의 신청서류를 검토한 후 적정하다고 판단하여 토석채취허가(이하 '이 사건 처분'이라 한다.)를 하였다. 한편, P산지 내에는 과수원을 운영하여 거기에서 재배된 과일로 만든 잼 등을 제조·판매하는 영농법인 甲이 있는데, 그곳에서 제조하는 잼 등은 청정지역에서 재배하여 품질 좋은 제품이라는 명성을 얻어 인기리에 판매되고 있다. 그런데, 甲은 과수원 인근에서 토석채취가 이루어지면 비산먼지 등으로 인하여 과수원에 악영향을 미친다고 판단하여, 이 사건 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 위 사안에서 丙이 토석채취허가신청을 하였으나, 乙이 이 사건 처분을 하기 전이라면, 甲은 乙이 이 사건 처분을 하여서는 안 된다는 소의 제기가 허용되는가? (30점)》

<문제1의 물음2> 관할행정청의 처분 전에 제3자가 예방적으로 처분 금지를 구하는 소송의 허용 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 丙은 토석채취허가를 신청하였으나 아직 허가처분이 이루어지지 않은 상태에서, 과수원을 운영하는 甲이 장차 이루어질 토석채취허가처분을 하여서는 안 된다는 취지의 소를 제기하고자 한다. 쟁점으로 <행정청이 아직 처분을 하지 않은 단계에서 장래의 처분을 금지하는 예방적 금지소송의 제기가 현행 행정소송법상 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 위 사안에서 丙이 토석채취허가신청을 하였으나, 乙이 이 사건 처분을 하기 전이라면, 甲은 乙이 이 사건 처분을 하여서는 안 된다는 소의 제기가 허용되는가를 설명한다.

II. 소의 대상적격

1. 취소소송의 대상

- "행정소송법 제4조"는 취소소송을 행정청의 위법한 처분등을 취소 또는 변경하는 소송으로 규정하고 있다. 따라서 취소소송의 전제가 되는 소송대상은 반드시 행정청의 처분등이 존재하여야 한다.

2. 처분 개념

- "대법원"은 처분을 행정청의 공권력 행사 또는 그 거부, 기타 이에 준하는 행위로서 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하는 행위라고 정의한다. 따라서 단순한 신청이나 행정청 내부의 검토는 처분이 아니며, 외부에 대해 직접적 법률효과를 미치지 않는다.

III. 예방적 금지 소송의 허용 여부

1. 예방적 금지 소송의 의의

- 예방적 금지 소송이란 장래 행정청이 행할지도 모르는 처분을 미리 금지해 달라고 청구하는 소송을 말한다. 이는 아직 구체화되지 않은 행정작용을 대상으로 한다는 점에서, 행정쟁송의 기본 구조인 사후적 구제구조와 대비된다.

2. 예방적 금지 소송의 원칙적 부정

- "판례"와 다수설은 예방적 금지 소송을 인정하지 않는다. 그 근거는 다음과 같다. ① 행정소송법상 취소소송은 이미 존재하는 처분을 대상으로 한다는 점에서 법문상 근거가 없다. ② 행정청의 장래 행위를 미리 법원이 통제하는 것은 행정재량을 과도하게 제약하여 권력분립원리에 반한다. ③ 실제 처분이 발령되지 않을 수도 있음에도 미리 소송을 허용하는 것은 사법자원의 낭비를 초래한다.

3. 예외적 허용 필요성 논의

- 그러나 환경권·건강권과 같은 기본권 침해는 일단 발생하면 회복이 극히 곤란하다. 따라서 사후적 구제만으로는 실효적 권리보호가 곤란한 경우 예방적 구제의 필요성이 인정될 수 있다. 일부 학설은 헌법상 권리보호 요청을 근거로 금지소송을 예외적으로 허용해야 한다고 주장한다.

4. 판례의 태도

- "대법원"은 행정소송으로서 금지소송을 인정한 사례는 없다. 다만, "헌법재판소"는 원자력발전소 부지사건 등에서 예방적 구제 필요성을 부분적으로 긍정하였다. 그러나 이는 행정소송이 아니라 헌법소원심판의 영역에서이다. 따라서 현행 행정소송법 해석상 금지소송의 허용은 극히 제한적이다.

5. 대체적 구제수단

- 금지소송이 인정되지 않는 대신, ① 행정절차법상 의견제출·청문 참여, ② 처분 발령 후 집행정지 신청, ③ 헌법소원 등 다른 제도적 장치가 존재한다. 따라서 법제는 금지소송을 부정하면서도 다른 경로를 통해 예방적 구제의 기능을 보완하고 있다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 소송 형태 검토

- 甲은 '군수 乙이 허가처분을 하여서는 아니 된다'는 취지로 소송을 제기하고자 한다. 그러나 이는 허가처분이 발령되기 전 단계의 예방적 금지소송에 해당한다. 행정소송법상 소송의 대상으로서 처분이 존재하지 않으므로, 원칙적으로 부적법하다.

2. 예외적 허용 가능성

- 토석채취로 인한 비산먼지 발생은 과수원 농작물의 오염, 잼 제품의 품질 저하, 영농법인의 영업상 신뢰 손상 등 회복하기 어려운 피해를 초래할 수 있다. 따라서 甲의 입장에서 예방적 구제의 필요성이 강력하다고 주장할 수 있다. 그러나 현행 행정소송 구조와 "판례"의 태도에 비추어 볼 때, 금지소송을 허용할 법적 근거는 부족하다.

3. 가능한 구제수단

- 甲은 허가처분이 실제 발령되면 즉시 취소소송을 제기하고, 동시에 집행정지를 신청하여 허가의 효력을 정지시키는 방식으로 권리보호를 도모할 수 있다. 또한, 허가절차 진행 중에는 행정절차법에 따른 의견제출·청문을 통해 적극적으로 자신의 이해관계를 주장할 수 있다.

V. 결론

- 본 사안에서 甲이 제기하고자 하는 乙은 토석채취허가처분을 하여서는 안 된다는 소송은, 허가처분이 발령되기 이전 단계에서 제기되는 예방적 금지소송에 해당한다. 그러나, 행정소송법상 취소소송은 이미 존재하는 처분을 대상으로 함을 전제로 하므로, 이러한 예방적 금지소송은 원칙적으로 허용되지 않는다. 따라서 甲은 허가처분이 실제로 발령된 이후 취소소송을 제기해야 하며, 처분 전 단계에서는 행정절차 참여, 처분 후에는 집행정지 신청 등을 통해 실질적인 권리구제를 도모해야 한다. 결국 본 사안에서 甲의 소송은 허용되지 않는다고 보아야 한다.